을 각하하고, 집행개시 후에 발견되면 집행절차를 직권취소하여야 한다는 것이 판례이다.[1] 이는 집행권원에 기한 강제집행의 전체에 대한 것으로, 어떤 물건의 압류금지 등 개개의 집행절차나 집행행위에 특별한 장애사유가 있는 경우와 구별된다. 집행장애 사유에는 다음 4가지가 있다.

(1) 도산절차의 개시(장애사유 1)

대표적인 강제집행의 장애사유이다. 채무자의 전재산에 대하여 전채권자를 위한 도산절차가 개시된 경우이므로 채무자의 특정재산으로 일부채권자를 위한 권리실현을 해 줄 상황이 아니기 때문이다. 채무자 회생 및 파산에 관한 법률, 이른바 통합도산법에 의하면 기업회생절차, 채무자회생절차의 개시결정[2]과 파산선고시 강제집행·보전처분은 허용되지 아니하며, 이미 행한 강제집행은 중지되므로 집행장애사유가 된다.[3] 도산절차가 개시된 것을 모르고 집행법원이나 보전법원이 강제집행이나 보전처분을 하는 혼선을 피하기 위해서는 법원내부에 정보공유시스템을 구축하여 일원적으로 등록·검색하는 것이 바람직하다는 외국의 논의가 있다.

판례는 임금채권 등 재단채권에 기하여 파산선고 전에 강제집행이 이루진 경우에도 그 강제집행은 파산선고로 인하여 실효된다고 하였다.[4] 그러나 채무자에 대한 청산절차가 진행중이거나 파산신청이 있다는 사정만으로는 집행장애사유가 된다고 할 수 없다.[5] 파산선고와 동시에 폐지결정을 하여 일단 파산절차가 종료한 뒤라도 면책신청을 한 때에는 그 신청에 대한 재판이 확정

1) 대법 2000. 10. 2, 2000마5221; 동 2008. 11. 13, 2008마1140. 그러나 독일·일본은 당사자가 원용하거나 집행기관에 알려진 경우에 조사한다는 것이 통설이다. 소송장애사유가 직권조사사항이 아닌 것과 마찬가지이다.

2) 회생개시결정 전에도 중지명령이나 포괄적 금지명령에 의하여 보전처분·강제집행을 중지시킬 수 있다(채무자회생 43조~45조).

3) 포괄적 금지명령에 반하여 이루어진 회생채권에 관한 보전처분이나 강제집행은 무효(대법 2016. 6. 21, 2016마5082). 구법상의 판례이나 회사정리절차개시 후의 추심명령이 무효하는 것에 대법 2004. 4. 23, 2003다6781. 개인회생재단에 속하는 재산에 대하여 이미 계속된 강제집행, 가압류 또는 가처분 절차는 개인회생절차가 개시되면 일시적으로 중지되었다가 변제계획이 인가되면 그 효력을 잃는다(대법 2008. 1. 31, 2007마1679). 재항고법원에서도 개인회생절차의 채권자목록에 기재되었음을 이유로 압류 및 전부명령을 취소하고 그 신청을 기각할 수 있다(대법 2011. 4. 20, 2011마3).

4) 대법 2008. 6. 27, 2006마260.

5) 대법 1999. 8. 13, 99마2198·2199. 미국 파산법 Chapter 11의 파산보호신청의 경우와 같은 automatic stay order의 도입여부가 법개정시 논의되었으나 채택되지 아니하였다.

될 때까지는 채무자의 재산에 대하여 강제집행을 할 수 없다(회생 557조).

개인파산절차와 개인회생절차가 증가일로에 있고 채무의 면책을 위해 성행·남용되는 현실이기 때문에 집행채권자의 강제집행이 난관에 이르는 경우가 많아 문제이다.[1] '빚으로부터 해방', '개인 빚, 카드 빚 끝'이라고 외치며 제도남용을 부추기는 경향도 있다.[2] 도산절차가 압류를 풀어주는 절차로 악용되어서는 안 될 것이다. 금융감독위원회에서 허가받아 설치되는 신용회복위원회는 5억원 이하의 금융채무에 대하여 부동산집행은 별론 소액채권·유체동산의 강제집행 중일 때에도 자율조정이 가능하며 정지의 효과가 나타난다(개인 work-out). 다만 담보권·전세권을 가진 자 등 별제권자의 경우는 임의경매가 가능하여, 집행장애가 안된다(동법 412조, 586조).

(2) 집행채권의 압류·가압류(장애사유 2)

甲의 乙에 대한 집행채권이 甲의 채권자 A에 의하여 압류·가압류되었다면 甲의 집행채권은 집행장애사유가 되는가. A에 의한 압류의 효과로서 甲이 자기의 집행채권을 추심하여 강제집행에 의한 만족의 단계에까지는 끌고 갈 수는 없으나 乙의 재산에 대한 압류는 가능하다는 것이 판례[3]이고 다수설이다. 그것은 집행채권의 현금화나 만족적 단계에 이르지 아니하는 보전적 처분으로서 집행채권을 압류한 A를 해하는 것은 아니기 때문이다. 따라서 집행개시까지는 막는 것이 아니므로 엄밀하게는 완전한 집행장애사유라기보다는 제한적 장애사유일 뿐이다.[4] 압류나 가압류가 해제되면 집행장애사유가 없어진다.

(3) 집행계약(장애사유 3)

집행계약이란 강제집행에 관한 집행채권자와 그 채무자 간의 합의이다. 합의가 법적으로 적법하고 집행을 제한하는 내용이면 집행장애사유가 된다. 집행문 없는 집행, 압류금지물의 집행과 같은 집행확장계약은 부적법하지만, 집행배제계약이나 집행제한계약은 사적자치의 영역에 속하므로 유효한 것임은

---

1) 미국에서는 2005년에 '파산 남용 방지 등 법률'이 제정됨.

2) 이시윤, "민사집행법상의 몇 가지 立法論的 問題", 법률신문 2010. 5. 3.자.

3) 대법 2000. 10. 2, 2000마5221; 동 2016. 9. 28, 2016다205915.

4) 이와 관련하여 압류·현금화·만족(배당)의 3단계로 나누어지는 강제집행단계에서 어느 단계까지 허용되는가에 관하여, 실무에서는 배당절차까지 속행하되 압류채권자의 채권액을 공탁하여야 한다는 설이 우세하다. 법원실무제요, 민사집행(Ⅰ), 233면.

주택 등의 소액임차보증금채권[1] 중 일정액. 최우선특권이기 때문이다. 최종 3개월분의 임금, 최종 3년간의 퇴직급여등과 재해보상금은 사용자의 총재산에 대하여 질권·저당권·동산담보에 따라 담보된 채권, 조세·공과금등에 우선하여 변제하도록 되어 있으므로(근기 38조 2항, 근로자퇴직급여보장법 12조 2항) 사용자가 사용자 지위를 취득하기 전에 설정한 질권 또는 저당권에 따라 담보된 채권에도 우선하여 변제되어야 한다.[2] 위 최우선권리 상호 간에는 배당순위에 우열이 없으나 최소한 중복 경매신청 또는 압류등기 전에 대항요건을 갖추고 배당요구종기까지 배당요구를 하는 등 각자의 우선배당을 위한 요건은 갖추어야 한다. 최종 3년간의 퇴직급여등은 배당요구종기일 전에 퇴직금지급사유가 발생하여야 한다.[3]

소액임차인의 지위[4] 소액임차인과 우선변제받을 채권액은 계속 인상되고 있는데, 2024. 9. 현재 서울특별시의 경우(타 지역은 더 낮다) ① 주택은 보증금 1억 6,500만원 이하 중 5,500만 원(주택시행령 10조, 11조), 상가는 보증금 6,500만원 중 2,200만원(상가시행령 6조, 7조)이고, ② 압류등기보다 선순위의 임차인이면 된다. 위 요건은 경매개시등기(압류등기)시를 기준으로 해당 여부를 판단할 것이다.[5] 저당권보다 후순위라도 문제되지 않으므로 저당권설정 후의 소액임차인은 보호받는다. 따라서 (i) 선순위의 저당권에 큰 위협이며 최우선권을 인정하는 소액보증금 만큼 저당물 담보가치가 저평가되는 요인이 된다. (ii) 임대차계약서가 확정일자로 공인되지 아니한 경우에는 체결일자, 보증금액 등을 조작하여 소액임차보증금 대상으로 만들 가능성을 배제할 수 없다. 일본은 저당권보다 후순위라도 저당권에 대항할 수 있는 단기임대차제도를 남용이 문제되어 2002년에 폐기하였다(일민 307조). ③ 소액임차인은 주택의 경우 5,500만원, 상가의 경우 2,200만원을 최우선변제받고, 나머지 보증금은 확정일자를 갖춘 경우에는 저당권자와 동순위로 우선변제, 확정일자가 없으나 대항력을 갖춘 경우

1) 대법 1999. 7. 23, 99다25532은 대지에 대한 저당권이 설정된 뒤에 신축된 건물의 소액임차인에게 우선변제권까지 인정하지 않으면서 그 이유를 공시방법이 불완전한 소액임대차제도로 저당권자가 입을 불측의 손해를 방지하기 위한 것이라고 하였다.

2) 대법 2011. 12. 8, 2011다68777.

3) 대법 2013. 11. 14, 2013다27831.

4) 대법 2008. 5. 15, 2007다23203(임대차계약 당시에는 소액임차인에 해당되지 않았지만, 그 뒤 새로운 임대차계약에 의하여 보증금을 감액하여 소액임차인에 해당되게 되었다면 소액보증인으로 보호받을 수 있다).

5) 저당권설정 당시에는 점포 및 사무실용이었으나 그 뒤 주거용건물로 용도 변경된 경우에 주택의 소액임차인 최우선변제권을 인정할 것이라는 것에, 대법 2009. 8. 20, 2009다26879(저당권자에 불의의 타격임).

에는 매수인에게 인수된다. ④ 매각대금의 1/2 한도 내에서 우선배당을 받되, 주택과 대지의 일괄경매시 대지의 매각대금부분에서도 우선변제된다(주택 8조). 일괄경매가 아니라 대지 부분만 별도로 경매될 경우에도 대지의 경매대금에서 우선변제를 받을 수 있다는 것이다.[1] 여러 필지의 임대주택대지 중 일부만 타인에게 양도되어 일부대지만이 경매되는 경우 임차인은 대지경매대금에 대하여 우선변제받을 수 있다.[2] 임대차 성립당시 임대인의 소유대지가 경매된 경우에도 마찬가지라고 본다.[3] 다만 건물이 저당권설정당시 존재하는 경우이어야지 그 설정 후 신축된 경우는 우선변제를 받을 수 없다.[4]

② **2순위**: 당해세, 즉 조세 중 당해 부동산자체에 부과된 세금이나 가산금(증여세 · 종부세 · 재산세 등 당해세. 국세기본 35조 3항, 지방세기본 71조 1항 3호).[5] 법정기일이 담보권 설정일보다 뒤라도 상관없다.

③ **3순위**: 담보권에 앞서는 일반조세 · 공과금인데 담보물권 설정 이전에 법정기일이 도래한 조세채권 등을 말한다(국세기본법 제35조 1항, 2항). 조세채권 사이에는 압류선착주의에 의하여 먼저 압류한 것이 선순위이다.[6] 경매한 뒤에 원소유자에게 부과되는 양도소득세는 매수인이 대금을 완납한 뒤 목적물이 매수인에게 넘어간 뒤에야 성립 · 확정되기 때문에 배분절차에 포함될 수 없다.

④ **4순위: 조세 등에 뒤지는 담보권** 조세의 법정기일 후에 설정된 저당권 · 가등기담보권 · 전세권[7] · 등기명령에 의하여 등기된 임차권(주택 3조의3 5항). 담보권상호간에는 먼저 한 **등기순위배당**이 원칙이다. 확정일자를 갖춘 주택 등 임대차보증금채권(주택 3조의2; 상가 5조 2항)은 담보권이 되므로 위와 같다(등록순위, 등록선착주의).

압류등기 후에 취득한 후순위저당권 담보다등기의 경우에도 배당요구를 했으면 여기에 포함되지만 압류채권자에 우선하여 배당받을 수는 없다. 다만 등기로서는 압류등기가 앞서지만, 권리로서는 채권인 압류채권이 물권인 저당

1) 대법 1996. 6. 14, 96다7595.
2) 대법 2012. 7. 26, 2012다45689.
3) 주석 민사집행법(Ⅱ), 992면; 대법(전) 2007. 6. 21, 2004다26133도 같은 취지이다.
4) 대법 1999. 7. 23, 99다25532.
5) 당해세 우선원칙을 정한 입법취지 및 당해세에 해당하는지 여부의 판단은 대법(전) 1999. 3. 18, 96다23184; 동 2007. 2. 22, 2005다10845 등 참조.
6) 대법 2005. 11. 24, 2005두9088(당해세를 제외한 조세채권과 담보물권 사이의 우선순위는 그 법정기일과 담보물권 설정일의 선후에 의하여 결정하고, 이와 같은 순서에 의하여 매각대금을 배분한 후 압류선착주의에 따라 각 조세채권 사이의 우선순위를 결정하여야 한다).
7) 전세권자가 주택 · 상가건물임대차보호법상의 우선변제권을 같이 갖춘 경우에는 이들 법에 의한 보호도 받게 된다는 것에, 대법 1993. 12. 24, 93다39676.

권에 앞설 수 없어 후순위저당권자가 압류채권자와 동순위의 평등배당의 관계가 된다. 저당권 등의 취득 후 집행절차에 참가한 채권자보다 우선배당받을 수 있느냐의 문제에 관하여 우리 판례는 압류에 관한 개별상대효설에 의하므로 이를 긍정한다(안분흡수, 앞의 「압류의 효력」 참조).

확정일자를 갖춘 보증금채권자의 지위를 더 살펴본다.[1]

(i) 주택 등 임대차보호법(주택 3조의2 3항; 상가 5조 3항)에서 임차인은 임대목적물을 매수인에게 인도하지 아니하면 보증금을 수령할 수 없으므로 배당실시로 보증금을 줄 때에는 임차인이 임대목적물을 매수인에게 인도하였는지 여부를 매수인의 명도확인서 등으로 확인하고 교부할 것이다.[2] 등기명령에 의한 등기임차권자일 때는 다르다. 임차인에게 보증금 전액을 배당하는 배당표가 확정될 때 임대차가 소멸한다.[3]

(ii) 여기의 보증금채권자는 대항력+확정일자를 겸유한 임차인이 되는데, 나아가 전세권자(91조 4항 단서)의 경우처럼 실제로 배당을 요구하여(88조) 우선변제를 선택한 자일 것을 요한다. 이러한 임차인이 전액배당을 못 받아 잔액이 있으면 그 반환받기까지 임대차가 존속되기 때문에 목적물을 유치할 수 있다.[4] 결국 잔액은 매수인이 승계인수되게 된다. 경매청구권이 없을 뿐 가장 강력한 법정담보물권이다.[5]

(iii) 미등기건물의 임차인에 대하여서도 전원합의체 판결로 종전 판례를 변경하여 우선변제권을 인정하였다.[6] 임차권 양수인도 우선변제권을 행사할 수 있고, 전차인도

---

1) 주택임차인에게 보증금우선변제권을 인정하기 위하여 읍·면·동사무소에 임대차등록부를 배치하여 보증금 등의 기재, 임차인에게 매수청구권과 경매청구권을 인정하자는 주장에, 민일영, "주택 경매에 있어서 임차인 보호에 관한 연구"(서울대 박사학위논문).

2) 동지; 박두환, 329면. 그런데 실무는 주택 또는 상가건물의 임차인, 임금채권자처럼 채권자가 집행력 있는 정본이나 채권증서를 가지고 있지 아니하는 경우에는 배당을 실시할 때 그 채권자로 하여금 영수증, 임대차계약서 등을 제출하게 하여 채무자에게 교부한다(159조 2항 참조). 주석 민사집행법(Ⅱ), 1129면; 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 205면 참조.

3) 대법 2004. 8. 30, 2003다23885.

4) 대법 2001. 3. 27, 98다4552; 동 2001. 3. 23, 2000다30165; 동 2006. 2. 10, 2005다21166 등. 주택임대차보호법 제3조의5가 신설되었음을 이유로 이에 반대설에는, 민일영, 경매와 임대차(2009), 409면.

5) 전액배당이 되지 아니하면 배당에 불구하고 임차권이 소멸되지 않고 배당받지 못한 보증금잔액의 한도에서는 매수인에게 인수되어 물어주어야 하며, 특히 소액임차보증금 중 일정액은 주택과 토지의 일괄매각시에 토지매각대금에서까지 배당하여야 하는 등의 주택 등 임차권의 특례는 오히려 배당선택시에는 소멸되는(91조 4항 단서) 전세권보다 더 후한 보호이다. 채권인 임차권을 물권인 전세권보다 더 보호하는 면이 있다. 차라리 임차권자에게 우선변제권은 배제하고 보증금전액반환 때까지 임대차가 존속하는 것으로 **유치적 효력**(유치권)만을 부여하는 것으로 일원화하면 임차권자보호도 되고 부동산 매각절차가 간소화될 것이다(주택 4조 2항, 상가 9조 2항 참조).

6) 대법(전) 2007. 6. 21, 2004다26133.

우선변제권을 대위행사할 수 있다.[1] 그러나 임차권과 분리하여 보증금채권만의 양수인은 우선변제권을 행사할 수 없다는 것이 판례이다.[2] 보증금없는 단순한 월세입주자는 우선변제권이 없어 제외된다.

⑤ **5순위**: 임금 · 퇴직금 · 재해보상금 · 기타 근로관계채권(근기 38조 1항; 근로자퇴직급여 보장법 12조 2항). 4순위 담보권과 6순위 담보권에 뒤지는 일반조세채권 사이에서 이것들이 5순위로 자리를 잡게 되는 근거는 근로기준법 제38조 1항 단서와 근로자퇴직급여보장법 제11조이다.

도표 2-10 임대차보호법상의 임차인의 지위*

대상 / 내용	주택	상가건물
적용범위	주택일반	보증금9억 이내(서울)
등기와 같은 대항력	인도＋전입신고	인도＋사업자등록
우선변제권	대항력＋확정일자(배당요구 필요)	주택과 같음
변제받지 못한 잔액	매수인에 대항(임대차 존속)	매수인에 대항
보증금받지 못한 때	임차권등기명령신청＝집행법의 가압류절차준용	주택과 같음
보증금반환채권 이행 · 집행의 특례	임차권 등기말소 미리 해주지 않아도 됨(2005다4529). 목적물인도는 집행개시요건 아님	주택과 같음
경매시 하자담보책임의 강화	민법 578조, 575조 1항 · 3항	주택과 같음
소액임차인의 지위	보증금 1억 6,500만원 중 5,500만원(서울, 단 매각대금 중 1/2 한도 내)＝최우선특권.	보증금 6,500만원 중 2,200만원(서울, 단 매각대금 1/3 한도 내)＝최우선특권
	압류금지	
	선순위저당권에 우선	주택과 같음

* 임차인의 지위는 등기공시가 되지 아니하며 그 내용을 정확히 파악할 수도 없는 대세적 절대권. 임대인 역차별의 문제점 있으나, 경매신청권 없음(다만 전세권설정이나 따로 집행권원을 얻어 경매신청권확보의 방법이 있음).

** 이에 대하여 임대인은 임대차계약을 하면서 임차인이 2회 임대료 연체시에 임대인에게 인도한다는 내용의 제소전화해조서를 작성하여 두었다가 조건성취집행문(임대료변제는 채권자인 임대인의 증명책임사항이 아니기 때문에 조건성취집행문 대상이 아님)이 아닌 단순집행문을 받아 명도집행하는 기습공격의 횡포(상가건물 임대차의 경우)의 사례도 있을 수 있다.

1) 대법 2010. 6. 10, 2009다101275.

2) 대법 2010. 5. 27, 2010다10276. 그러나 서울고법 2012. 9. 6, 2012나25373은 우선변제권은 전속적 권리로 제한할 수 없음을 근거로 이와 배치되는 판결을 하였다.

연기 등 실체법상의 사유를 경매개시결정에 대한 이의사유로 삼을 수 없는 것과 대조적이다. 집행권원은 어렵게 만들어졌으므로 청구이의의 소로 어렵게 다투도록 하였다. 불복방법의 차이이다. 담보권실행의 경매에서도 채무부존재확인소송, 담보권부존재확인소송, 저당권설정등기말소청구소송 등 채무이의소송이 실무상 널리 행하여지지만, 반드시 그것만이 아니라 경매개시결정에 대한 이의제도에 의해서도 해결할 수 있다(실체이의 · 실체항고). 다만 후자로는 기판력을 얻을 수 없다.

넷째, 집행정지 · 취소문서와 관련하여 강제집행은 재판의 정본(집행권원의 취소, 집행정지결정 등)이 중심이 되지만, 담보권실행의 경우는 재판정본 이외에 저당권설정등기 말소등기 등이 된 **등기사항전부증명서**를 내도 된다. 강제집행의 취소결정에 대해서는 즉시항고를 허용하나(17조), 담보권실행의 취소결정에 대해서는 그 원인인 취소사유가 명료하다는 이유로 즉시항고를 인정하지 아니한다(266조 3항).

다섯째, **집행장애**와 관계해서도 차이가 있다. 채무자에 대한 파산 등 도산절차가 개시되면 강제집행은 더 이상 허용되지 아니한다. 그러나 담보권자는(유치권 · 질권 · 저당권 · 전세권) 채무자가 파산선고가 받아도 별제권(別除權) 때문에 경매를 진행할 수 있다(도산 412조, 586조).

여섯째, 압류등기 전 압류부동산의 **제3취득자의 지위**와 관련하여 강제경매에서는 제3취득자가 압류신청 · 압류사실을 모른 선의일 때에는 경매절차를 취소시킬 수 있으나, 담보권실행의 경매에서는 선의라도 취소할 수 없다(92조 2항).

일곱째, **절차종결**에서도 차이가 있다. 강제경매에서는 유효한 집행권원에 의하여 경매절차가 끝났으면 전면적 공신력을 인정한다. 즉 집행권원에 표시된 집행채권의 부존재 · 소멸이 있더라도 매수인이 대금을 완납하면 유효하게 소유권을 취득한다. 그러나 담보권실행의 경우는 담보권증명서류에 표시된 담보권의 부존재 · 원인무효 등의 사유가 있으면 매수인이 매각대금을 완납하여도 목적물의 소유권을 취득하지 못하고,[1] 다만 **담보권**이 소멸된 경우에만 매

1) 대법 1975. 12. 9, 75다1994; 동 1999. 2. 9, 98다51855. 일본법은 담보권의 부존재 · 소멸 모두 경매거래의 안전을 위하여 소유권취득에 영향이 없는 것으로 하였고, 그것이 필자의 1990년 법률개정시의 주장이었으나 절충적으로 담보권소멸시만 소유권취득에 영향 없는 것으로 수정되었다.

실은 방관만 할 것이 아니므로 법 개정이 필요한 부분이다.[1]

넷째, 부동산경기의 침체에 의한 건물가격의 하락은 소위 '깡통주택(주택담보대출금과 전세보증금의 합산액이 매매가격의 80%를 넘는 주택)'의 발생시키는 문제를 낳고 있다.[2] 다시 말하면 담보가치 대비 대출비율인 담보인정비율(LTV=Loan to value)이 넘는 주택담보대출이 엄청난 규모라고 한다. 그런데 경매로 인한 낙찰가율이 70% 정도라니 은행이 저당권을 실행하여도 집행비용을 부담하면 전액 대출금회수가 곤란하게 되어 금융기관의 건전화에 악영향을 줄 수 있다. 대출금은 물론 전세금도 경매로 회수가 어렵게 된 사례가 최근에 다수 발생하였다. 담보대출금 이하 담보집값 하락 → 압류주택증가 → 집값추가하락을 유발하여 미국발 subprime mortgage 사태의 우려를 배제할 수 없다. 또한 금융기관(은행, 저축은행, 카드사 등)이 담보대출금의 회수가 어려운 경우에는 피담보채권액 이하로 매각하는 NPL(non performance loan)채권이 늘어날 수 있다. 현재 1,000조원이 넘어서는 가계대출이 대부분 주택담보대출이므로 주택값이 떨어지면 문제는 심각해질 수 있다.

이에 채무자가 담보주택을 금융기관에 신탁하면서 5년간 경매를 유예해 두고 그동안 임대료를 내고 살다가 5년 뒤 원금을 갚아서 주택을 다시 찾게 하는 trust and lease back 제도도 일각에서 구상하는가 하면, 금융권이 일단 3개월간 경매를 유예해 주고 주택매매를 중개하는 방안을 제2금융권까지 확대하는 방안도 나오고 있다(하우스푸어대책). 후자가 채권자 주도형의 임의경매라 할 수 있는데, 대체적 분쟁해결제도(ADR)라 할 수 있다. 금융권의 담보권행사 과정에는 감독기관의 규제보다는 자율적 운영의 통로를 열어주어야 한다.

도표 3-1 강제경매와 담보권실행의 경매비교

절차 / 항목	강제경매	담보권실행경매(임의경매)
기초	집행권원	담보권존재증명서(저당권이 기재된 등기사항증명서) 등
행사	집행문	집행문불필요
청구이의의 소 ·	있음	없음

1) 김갑수, "경매절차에 있어서의 송달에 관한 고찰", 민사집행법연구 제6권, 325~329면.
2) 게다가 소위 up 계약으로 담보가치를 부풀린 뒤에 초과대출받는 사례도 많다.

집행문부여의 이의		
집행권의 부존재 · 소멸을 다투는 절차	청구이의의 소	경매개시결정에 대한 이의신청
집행정지	집행권원 취소의 재판 · 집행정지의 재판정본 등(49조 · 50조)	저당권설정등기말소사항증명서 등(266조)
배당관계	평등배당	우선배당
대금완납 후 소유권취득	집행채권의 부존재 · 소멸되어도 영향 없음	담보권의 소멸시에만 영향 없음
통지 · 송달	교부송달 · 보충송달 등	KAMCO 경매시는 발송송달
도산절차와 관계	집행장애사유	별제권으로 집행장애 없음

제 2 절 부동산담보권의 실행

부동산담보권에는 전세권 · 가등기담보권도 있어 저당권이 전부를 이루는 것은 아니나, 그 중요성이나 이용비율로 보아 저당권이 단연 압도적이다. 담보권실행의 부동산경매에는 부동산의 강제경매에 관한 민사집행법 규정은 물론 민사집행규칙도 대부분 준용된다(268조, 규 194조). 아울러 강제집행 총칙규정도 일부 준용한다(275조; 규 202조). 절차부분이 거의 공통적이므로 예외 4개의 조문(264조 내지 267조)을 빼고는 **전적인 준용**이다.

부동산강제경매절차에 대한 특칙이라면 ① 경매신청서류(264조), ② 경매개시결정에 대한 이의사유(265조), ③ 경매절차의 정지(266조), ④ 매수인의 소유권취득과 담보권의 소멸(267조) 등 4가지뿐이다. 나머지는 부동산강제경매절차와 같다고 보면 된다. 담보권의 발생 · 변경 · 소멸은 민법 등 실체법에 규정되어 있는데 반하여, 그 실행절차는 민사집행법에서 다루어지는데, 그 절차는 경매신청 → 압류(경매개시결정) → 현금화 → 배당으로 진행됨은 강제경매와 차이가 없다. 강제경매규정의 준용 결과 담보권실행의 부동산경매에서도 잉여주의(91조 1항, 102조)가 적용된다. 또 부동산강제경매절차와 마찬가지로 부동산담보권의 실행경매도 법관이 아니라 **사법보좌관**의 업무로 되었다. 준부동산 중 선박담보권실행은 다르나 자동차 · 건설기계 담보권실행의 경매도 같다(사보규 2조 1항 11호). 담보권실행의 경매가 비록 강제경매규정을 거의 전적으로 준용

하는 체제이지만, 경매 사건수는 전자가 후자보다 많다.[1]

Ⅰ. 경매절차

1. 경매신청

(1) 경매신청의 방식

담보권의 실행은 담보권자가 집행법원에 경매신청을 함으로써 개시된다. 경매청구권이 없는 담보권 예컨대 확정일자를 갖춘 주택·상가건물임차권자는 여기의 신청권자에서 제외된다. 신청은 서면에 의하여야 한다(4조. 전자신청이 된다). 채권자대위권(민 404조)에 의한 대위경매신청도 가능하다.[2] 대위변제자도 채권자를 대위하여 경매신청을 할 수 있다.

신청서에는 채권자·채무자·소유자 이외에 담보권·피담보채권, 실행대상 재산 및 피담보채권의 일부에 대한 실행인 때에는 그 취지와 범위를 적게 되어 있다(규 192조). 경매대상건물이 인접건물과 합동되어 독립성을 상실한 경우는 합동으로 새로 생겨난 건물 중에서 차지하는 비율에 상응하는 공유지분에 관하여 경매신청을 하여야 한다.[3] 명문의 규정은 없어도 피담보채권의 변제기도래 사실은 적어야 한다. 신청인은 이와 같은 신청서와 다음의 첨부서류 외에 집행비용을 예납해야 한다(53조 1항).

경매신청에도 처분권주의가 적용된다. 따라서 채권자에 의하여 경매신청되지 아니하였고 경매법원으로부터 경매개시결정을 받은 바도 없는 독립한 부동산에 대하여 경매되었으면 당연무효이고, 매수인은 그 부동산을 취득할 수 없다.[4]

공동근저당권 목적부동산 중 하나의 부동산에 담보권실행경매의 진행 결과 담보된 채권최고액에 해당하는 전액을 배당받았다면 담보권의 소멸로 다른 부동산에 경매신청을 할 수 없다.[5]

---

1) 2023년에 접수된 부동산경매사건 80,729건 중 강제경매는 34,572건, 담보권실행등은 46,157건이고, 경매 중 강제경매와 담보권실행등의 비율은 매년 유사하다.

2) 김홍엽, 434면; 주석 민사집행법(Ⅵ), 187면.

3) 대법 2010. 3. 22, 2009마1385(독립성상실의 건물에 대해서는 직권으로 경락허가하지 아니하여야 된다). 유사취지는, 대법 2011. 9. 5, 2011마605.

4) 대법 1991. 12. 10, 91다20722.

5) 대법 2012. 1. 12, 2011다68012.

권의 행사방법과 시한을 제한하는 것은 대위물인 채권의 특정성 유지로 그 효력의 보전, 평등배당을 기대하는 일반채권자의 신뢰보호 등으로 제3자에게 불측의 손해를 입히지 아니함과 동시에 집행절차의 안정과 신속을 도모함에 취지가 있다고 한다.[1] 그 결과 담보물에 대하여 담보권등기가 된 것만으로는 보상금 등으로부터 우선변제를 받을 수는 없다(일반경매에서는 선순위담보등기만으로 배당된다).[2] 물상대위권을 제대로 행사하지 아니하여 우선변제권을 상실한 이상 다른 채권자가 보상금 등에서 이득을 얻었다 하여도 등기만을 한 저당권자는 부당이득반환청구를 할 수 없다.[3]

제 5 절 형식적 경매

형식적 경매란 청구권의 만족·보전을 목적으로 하지 않지만 담보권실행으로서의 경매의 예에 따라 법원경매에 부쳐 현금화를 실시하는 절차이다. 유치권에 의한 경매와 민법·상법, 그 밖의 법률이 규정하는 바에 따른 경매가 있다(274조). 후자만을 형식적 경매라고 하는 견해도 있으나,[4] 이는 좁은 의미의 형식적 경매라고 할 것이다. 좁은 의미의 형식적 경매는 **순현금화형**[5]과 **청산형**[6]이 있다. 매각에 의해 목적부동산 위의 부담이 소멸되느냐 인수되느냐에 대하여 학설상 인수설, 청산형만 소멸된다는 절충설이 있다. 대법 2009. 10. 29, 2006다37908은 공유물분할을 위한 경매, 이른바 형식적 경매도 강제경매나 담보권실행을 위한 경매와 마찬가지로 목적부동산 위의 부담을 소멸시키는

에서 물상대위권자로서 배당받을 수 있다고 하였다. 이 경우는 공탁사유신고가 배당요구차단의 효력이 생기지 않기 때문이다(대법 2007. 4. 12, 2004다20326).

1) 대법 2003. 3. 28, 2002다13539.

2) 대법 2002. 10. 11, 2002다33137.

3) 대법 2010. 10. 28, 2010다46756.

4) 방순원/김광년, 473면; 강대성, 559면.

5) 공유물분할을 위한 경매: 민법 490조, 상법 67조, 민사집행법 258조 6항 등의 자조매각: 단주의 경매: 상법 760조, 집합건물법 45조의 타인의 권리를 상실시키는 경매 등. 대법(전) 2020. 5. 21, 2018다879은 금전채권자가 채무자를 대위해서 공유물분할청구권을 행사할 수 없다고 하였다.

6) 한정승인, 재산분리에 따르는 상속재산의 경매 등으로서 민법 1037, 1051조 3항, 1056조 2항에 근거한 청산을 위한 경매임.

것을 법정매각조건으로 하여 실시된다는 소멸설을 취하였다.[1]

주로 문제되는 것은 유치권이다. 유치권에 경매권이 있는지 여부가 한 때 논의되었지만,[2] 민법 제322조 1항과 민사집행법 제274조에서 유치권에 경매청구권이 있음을 명확하게 하였다.

(1) 유치권의 경매신청권

경매신청은 부동산이면 집행법원, 동산이면 집행관에게 서면으로 한다(4조). 집행법원의 사무는 사법보좌관이 담당할 수 있다. **유치권의 존재를 증명하는 서류**(264조 1항 참조)를 집행기관에 제출할 것을 요한다. 그 서류에 의하여 유치권의 성립이 추정되면 경매를 개시한다.

(2) 유치권에 의한 경매정지의 경우

유치권에 의한 경매절차가 동일 목적물에 대하여 강제경매나 담보권실행의 경매와 경합적으로 개시되면 이를 정지하여야 하며, 강제경매나 담보권실행의 경매절차만을 속행한다(274조 2항). 유치권에 의한 경매절차가 정지되고 그 채권자를 위한 강제경매절차를 진행한 경우, 강제경매에서 목적물이 매각되더라도 유치권자의 지위에 영향이 없고 매수인이 유치권을 인수한다.[3] 그러나 뒤의 경매가 취소되면 형식적 경매를 속행한다(274조 3항). 다만 판례는 일부지분에 대한 강제집행 등 절차의 진행 중에 목적물 전체에 대한 공유물분할 경매가 개시되면 양절차를 병합하여 한꺼번에 매각할 수 있다고 했다.[4] 민법 제322조 2항에서 유치권자가 간이변제충당을 법원에 청구할 때에 미리 채무자에게 통지하게 하였는데, 유치권에 의한 경매신청의 경우에도 유치권자가 채무자에게 유치물을 경매에 부친다는 것을 미리 통지함이 타당할 것이다.

(3) 유치권의 소멸주의와 우선변제 여부

유치권에는 우선변제권은 없기 때문에, 유치권자는 경매대금에서 우선변

1) 대법 2009. 10. 29, 2006다37908(단 필요한 경우에 법정매각조건과 달리 부담을 인수시킬 수 있지만, 이러한 매각조건변경은 이를 고지하여야 한다).

2) 독일에는 우리의 유치권에 상응하는 권리를 인정하는 규정이 없고, 독일민법 제273조의 이행거절권은 채권관계상의 연기적 항변권인데, 일본과 이를 계수한 우리나라가 이를 물권적 성질의 물건인도거절권으로 오해하였다는 견해에, 강구욱, "유치권의 물권성에 관한 단상", 민사집행법연구 제15권, 349~350면.

3) 대법 2012. 9. 13, 2011그213.

4) 대법 2014. 2. 14, 2013그305.

권액의 계산에 있어 채무자가 다수의 직장으로부터 급여를 받거나 여러 종류의 급여를 받는 경우에는 이를 합산한 금액을 급여채권으로 한다(시행령 5조).

2) 압류금지채권의 추가 2005년, 2010년, 2011년 개정법률로 압류금지채권을 추가하였다. ① 퇴직금과 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권은 1/2(5호), ② 소액주택임차보증금(6호), ③ 저축성보험이 아닌 보장성보험의 보험금(해약환급 및 만기환급금 포함)(7호),[1] ④ 채무자의 1월간 생계유지에 필요한 예금(적금·부금·예탁금과 우편대체 포함)(8호)이다. 제8호에 따라 압류가 금지되는 예금은 채무자 명의의 어느 한 계좌에 예치되어 있는 금액이 아니라 개인별 잔액, 즉 각 금융기관에 예치되어 있는 채무자 명의의 예금을 합산한 금액 중 일정 금액을 의미한다.[2]

(2) 특별법상의 압류금지

사회정책적으로 압류를 전면금지시킨 채권이 많다. 공무원연금, 군인연금, 사학연금, 국민연금, 실업급여, 산업재해보상보험급여, 국가배상금 등이다. 건설공사의 도급금액 중 근로자에 지급할 노임채권,[3] 학교법인의 수업료 기타 납부금 수입[4]을 관리하는 별도계좌의 예금채권도 같다(사립학교 29조 2항, 28조 3항). 국민기초생활보장법상의 수급자가 받을 권리, 급여수급계좌의 예금채권(동법 35조), 소상공인이 불입하는 노란우산 공제금(중소기업협동조합법)도 같다.

또 성질상 양도금지채권도 압류금지채권이라 할 수 있다. 국가나 지방자치단체에 대한 보조금청구채권은 양도금지되는 것으로 압류금지채권이 된다.[5] 다만 헌법재판소는 우체국보험 및 환급금청구채권전액에 대한 압류금지조항(우체국예금·보험에 관한 법률 45조)은 헌법에 불합치한다고 하였다.[6] 조합원

---

1) 하나의 보험계약에 보장성보험과 저축성보험의 성격이 모두 포함된 경우에 저축성보험을 분리하여 압류할 수 없을뿐더러, 이때에는 보장성보험으로 보아야 한다는 취지의 것에, 대법 2018. 12. 27, 2015다50286.

2) 대법 2024. 2. 8, 2021다206356. 압류가 금지되는 1월간 생계유지에 필요한 예금에 양도성예금증서, 휴면예금 지급청구권, 공동명의 예금이 포함되는지 여부와 배당시에도 적용되어 채무자에게 배당하는 것이 옳은지 여부에 관하여는 이형범, "민사집행법 제246조 제1항 제8호의 적용범위에 관한 소고", 민사집행법연구 제11권, 189~227면.

3) 대법 2000. 7. 4, 2000다21048.

4) 육성회비, 특기·적성비, 보충수업비, 수학여행비도 여기에 해당된다는 것에, 대법 2001. 3. 20, 2000마7801.

5) 대법 2008. 4. 24, 2006다33586; 동 2009. 3. 12, 2008다77719 등.

6) 헌재 2008. 5. 29, 2006헌바5.

와 같은 입장이다.[1]

이에 대하여 추심명령이 있더라도 채권은 여전히 집행채무자에게 귀속되므로 채권자대위권이 행사된 경우와 마찬가지로 채무자의 소송수행권은 유지된다는 반대설이 있다.[2] 추심명령이 있더라도 채무자는 여전히 채권의 귀속주체이므로 집행채권자의 권리를 침해하지 아니하는 범위 내에서는 피압류채권에 관하여 채권자로서의 권리를 갖는다고 보는 것이 옳을 것이다. 판례는 추심금 청구의 소가 집행채권에 대해서만 시효중단의 효력이 있고, 피압류채권에 대해서는 최고로서의 효력밖에 없다[3]고 하는데 그렇다면 압류채권의 시효중단을 위해서도 채무자의 소송수행권은 필요한 것이라고 볼 것이다.[4]

2인 이상의 불가분채무자 또는 연대채무자가 있는 금전채권에 대하여 그 채무자 중 1인을 제3채무자로 한 압류추심명령이 발령된 경우, 집행채무자는 압류추심명령의 제3채무자가 아닌 나머지 채무자에 대해서는 여전히 채권자로서의 추심권을 상실하지 아니하므로 이행의 소를 제기할 수 있음은 어느 설에 의하여도 같다.[5]

추심명령이 있더라도 채무자는 여전히 채권의 귀속주체이므로 추심채무자는 제3채무자에 대하여 피압류채권에 기초하여 동시이행을 구하는 항변권을 상실하지 않는다.[6] 채권에 관한 **위험부담**도 채무자가 부담하므로 제3채무자

---

1) 김홍엽, 384면; 전병서 435면; 주석 민사집행법(Ⅴ), 723면; 양진수, "추심의 소와 채무자의 당사자적격, 중복된 소제기의 금지", 민사판례연구 37권(2015), 832~840면; 손진홍, 채권집행실무, 523면 등.

2) 이백규, "압류된 채권양수인의 이행청구과 추심명령", 민사판례연구 24권(2002), 520~524면; 최성호, "추심의 소와 중복소송에 관한 검토", 이화여자대학교 법학논집 18권 3호, 544면; 김세진, "이행소송 계속중 압류채권자가 제기한 추심소송의 중복제소 여부", 법조(2014. 9), 225면; 손흥수, 채권집행, 한국사법행정학회(2017), 55~356면; 강구욱, "금전채권에 대한 추심소송에 관한 재고", 민사집행법연구 제16권, 202면; 곽종훈, 법률신문(2024. 9. 12), 10면 등.

3) 다만 대법 2019. 7. 25, 2019다212945은 채무자의 제3채무자를 상대로 한 소송의 계속 중 추심명령이 발령되어 채무자의 소가 각하된 경우, 채무자가 권리주체의 지위에서 한 시효중단의 효력은 추심채권자에게도 미치므로 추심채권자가 6개월 안에 추심의 소를 제기하면 위 시효중단의 효력이 그대로 유지된다고 하였다.

4) Brox/Walker, Rdnr. 645. 채무자는 제3채무자를 상대로 압류채권자에게 압류채권의 이행을 구하는 소제기가 허용된다는 것은 BGH의 판례도 같다.

5) 대법 2013. 10. 31, 2011다98426(금전채권 중 일부에 대해서만 압류추심명령이 내려진 경우에도 같다).

6) 대법 2001. 3. 9, 2000다73490(제3채무자의 임대목적물 인도청구에 대하여 채무자가 압류추심된 보증금의 동시이행항변권을 행사한 사례).

에서 탈퇴할 수 있는데, 그 뒤에 제3자와 상대방 당사자 사이의 판결의 기판력·집행력은 탈퇴자에게 미친다. 탈퇴자에게 집행력이 미친다면 무엇이 집행권원이 되느냐가 문제인데, 탈퇴자에게 집행력도 미치므로 남아 있는 당사자의 소송에서는 그 판결주문에서 탈퇴자에 대한 이행의무를 선언할 것이며, 이 선언이 탈퇴자에 대한 집행권원이 된다고 할 것이다.[1] 그러므로 이 경우에는 탈퇴자를 채무자로 하는 집행권원이 존재하는 것이므로 단순집행문으로 충분하다.[2]

2. 집행당사자적격의 변동

(1) 집행문부여 전에 변동이 될 때

집행권원이 성립하고 나서 집행문의 부여 전에 승계 그 밖의 원인에 의하여 집행권원상의 당사자적격에 변동이 생기면 새로 당사자적격을 취득한 자를 위하여 또는 그 자에 대하여 승계집행문을 부여받아야 한다(가압류·가처분명령의 경우에는 292조 1항, 301조).

(2) 집행문부여 후에 변동이 된 때

집행문부여에 의하여 집행당사자는 확정되지만, 그 뒤라도 승계 등의 사유로 집행당사자로서 집행하거나 집행받을 적격에 변경이 생길 수 있다.

1) 집행문부여 후 **강제집행개시 전**에 그와 같은 변동이 생겼을 때에는 신적격자를 위하여 또는 그 자에 대하여 다시 집행문부여를 받지 아니하면 강제집행을 개시할 수 없다. 만일 집행개시 전에 집행문의 부여를 받지 않고 그대로 사망자를 위하여, 혹은 사망자에 대하여 행한 강제집행은 무효로 된다.

2) 집행문부여 후 **강제집행개시 후**에 변동이 생겼을 때에도 원칙적으로 신적격자를 위하여 또는 그 자에 대하여 다시 집행문의 부여를 받지 아니하면 강제집행을 속행할 수 없다. 규칙 제23조는 집행개시 후 채권자의 승계가 있을 때에는 승계집행문의 제출을 요하며,[3] 승계집행문이 제출된 것을 법원사무관 등 또는 집행관은 채무자에게 통지하여야 한다고 규정하였다. 소송절차의

1) 박두환, 71면. 잔존 당사자 사이의 판결에서 탈퇴자에 대한 의무이행의 기재가 없는 경우에는 추가판결을 신청하여야 한다는 견해와 직권 또는 신청에 의한 판결경정으로 시정하여야 한다는 견해가 있다. 주석 민사소송법(Ⅰ)(제9판), 한국사법행정학회(2023), 691면.

2) 주석 민사집행법(Ⅰ), 509면.

3) 집행공탁으로 배당절차가 개시된 다음 집행채권이 양도되고 양도통지가 되었더라도 승계집행문을 부여받아 집행법원에 제출되지 아니하면 집행법원은 양도인을 배당금채권자로 취급할 수밖에 없다는 것에, 대법 2019. 1. 31, 2015다26009.

수계(민소 233조 이하)와 같은 제도가 강제집행절차에 없기 때문이다. 그와 같은 변동이 생긴 것을 이해관계인의 통지나 신고에 의하여 집행기관이 알게 되었을 때에는 집행기관은 절차를 정지시켜 신적격자로 하여금 집행문의 부여를 받게 하는 등의 절차를 밟도록 촉구할 것이다. 그러나 집행기관이 이를 몰라 집행을 속행하였다면, 이때의 집행기관의 집행행위는 적법한 것으로 볼 것이다.[1] 대법 1993. 7. 13, 92다33251은 가압류결정의 피보전권리에 관하여 승계인이 된 것이 입증되었으면 가압류집행이 되기 전이면 제292조 1항에 따라 승계집행문을 부여받아 가압류집행을 할 수 있으되, 가압류집행이 된 뒤에는 승계집행문을 부여받지 아니하여도 가압류에 의한 보전의 이익을 자신을 위하여 주장할 수 있다고 하였다.[2]

(3) 채무자사망의 경우의 예외

집행개시 후 집행중에도 승계집행문을 부여받아야 하는 원칙에 대해 채무자 등 사망의 경우에는 **예외적**으로 부여할 필요가 없다. 구체적으로 본다.

강제집행개시 후에 채무자가 죽은 때이다. 이때는 승계집행문 없이 상속재산에 대하여 그대로 강제집행을 계속 진행할 수 있다(52조 1항). 다만 승계집행문 없는 계속 진행을 현재 집행의 대상이 되어 있는 상속재산이 아닌 다른 상속재산에까지 확장할 수 있다는 적극설이 있으나,[3] 제52조 1항이 예외규정이므로 확장해석은 적절치 않다.[4] 계속 진행은 현재 집행중인 당해 상속재산에 한정할 것이다. 승계인의 고유재산에 대한 강제집행이나 작위·부작위 의무의 강제집행(260조, 261조)에는 원칙에 따라 승계인에 대한 집행문을 필요로 할 것이다.

강제집행을 계속 진행할 때에 채무자측에 통지·송달·심문 등 채무자에게 알려야 할 집행행위를 실시하는 경우에는 상속인이나 그에 갈음하는 유언집행자·상속재산관리인 등에 대해 이를 행하여야 한다. 만일 상속인이 없거나 상속인이 있는 곳이 분명하지 아니하면 집행법원(사법보좌관의 업무)에 신청하여 상속재산 또는 상속인을 위하여 특별대리인을 선임할 것이다(52조 2항).

---

1) 주석 민사집행법(Ⅰ), 494면.

2) 가처분에 관한 같은 취지는, 대법 2015. 8. 27, 2013다43802·43819.

3) 박두환, 72면.

4) 김홍엽 33면; 전병서 55면; 김일룡 65면; 주석 민사집행법(Ⅰ), 495면; 서기석, "당사자의 사망이 재판 및 집행절차에 미치는 영향", 인권과 정의 266호(1998. 10), 50면.

무가 판결에 표시된 자 이외의 자가 실질적으로 부담하여야 할 채무자라 하여도 그 자에게 승계집행문을 부여할 수 없다고 하여 '실질적 채무자'이론을 부정하였다.[1]

1) 당사자의 사망과 소송중단 소송계속중 당사자 일방이 사망하여 소송절차가 중단되어야 함에도 이를 간과하고 판결이 선고된 경우에 이 판결에 기한 강제집행을 실시할 때에는 제31조를 준용하여 승계집행문을 부여할 것이다.[2] 그러나 소송계속중 소송승계사유가 있음에도 소송대리인이 있어 중단하지 아니한 채 진행되어 구 당사자명의로 판결이 난 때, 승계인에게 집행하고자 할 경우에는 당사자를 승계인으로 **경정**(更正)하면 된다.[3]

2) 점유승계와 가처분 부동산 인도 또는 명도판결의 변론종결 후에 그 부동산의 점유를 제3자에게 이전시킴으로써 승소자가 집행할 수 없게 되는 경우를 대비하여 그 점유승계인을 상대로 강제집행이 가능하도록 하기 위해 승계집행문 제도가 생긴 것이다. 점유이전금지가처분의 당사자항정효와 관련하여 점유이전금지가처분이 집행된 후 그 목적물의 점유를 승계한 제3자에 대하여 본안판결을 집행함에 있어서 승계집행문을 부여받아야 할 것인가에 관하여 견해의 대립이 있는데, 대법 1999. 3. 23, 98다59118은 승계집행문이 필요하다는 입장이다(뒤의 점유이전가처분의 효력 참조). 부동산의 점유자의 정체를 감추면서 점유자를 순차로 바꾸어 채무자의 특정을 어렵게 만드는 집행방해에 대처하기 위한 일본개정법과 같은 채무자불특정집행문제도의 도입이 필요하다.

3) 면책적 승계와 중첩적 승계 대법 2010. 1. 14, 2009그196은 당사자인 채무자의 지위를 승계하는 이른바 면책적 채무인수는 제31조 1항에서 말하는 승계인에 해당하지만, 중첩적 채무인수는 당사자의 채무는 그대로 존속하며 이와 별개의 채무를 부담하므로 소극적으로 해석하여야 한다고 했다.[4]

4) 상 속 승계의 대표적인 경우이다. 상속재산인 채권이 불가분채권인 경우 상속인 중 1인이 전원을 위하여 집행문부여를 구할 때에는 그 취지를

1) 대법 2002. 10. 11, 2002다43851 등.

2) 대법 1998. 5. 30, 98그7. 소송비용부담의 재판이 있은 후에 그 부담의무자가 사망하자 승계집행문을 부여받지 않고 그 상속인들을 상대로 소송비용액 확정신청을 한 경우, 그 신청은 소송비용부담재판의 당사자 아닌 자에 대한 것이어서 부적법하다는 것에, 대법 2009. 8. 6, 2009마897.

3) 대법 2002. 9. 24, 2000다49374.

4) 동지 대법 2016. 5. 27, 2015다21967.

승계집행문에 기재하고 내어줄 수 있다.[1] 가분채권인 때에는 자기 채권에 대한 이행청구를 할 수 있을 뿐이고 따라서 승계집행문에는 각 상속인에 대한 집행가능 한도로서 상속분의 비율 또는 그에 기초한 구체적인 수액을 기재해야 한다. 비록 그와 같은 기재를 누락하였다 하더라도 그 승계집행문은 각 공동상속인에 대하여 각 상속분에 따라 분할된 채무에 한하여 효력이 있다.[2] 숙려기간(민 1019조) 내라도 승계집행문을 구할 경우에는 추정상속인이라는 것과 피상속인의 사망을 증명하여 집행문의 부여를 받을 수 있고, 상대방은 숙려기간중이라는 사실, 상속을 포기한 사실을 내세워 집행문부여에 대한 불복절차로 다툴 수 있다.[3]

판례는 상속인은 아직 상속승인, 포기 등으로 상속관계가 확정되지 않은 동안에도 잠정적으로 피상속인의 재산을 당연취득하고 관리할 의무가 있으므로 상속채권자는 그 기간동안 상속인을 상대로 상속재산에 관한 가압류결정을 받아 집행할 수 있고, 이후 상속인이 상속포기로 상속인의 지위를 소급하여 상실하더라도 이미 발생한 가압류의 효력에는 영향이 없으므로 상속채권자는 종국적으로 상속인이 된 사람 또는 상속재산관리인을 채무자로 한 상속재산에 대한 경매절차에서 가압류채권자로서 적법하게 배당을 받을 수 있다고 하였다.[4] 그러나 집행채무자가 **상속포기**를 하였음에도 집행채권자가 상속을 원인으로 한 승계집행문을 부여받아 채권압류 및 전부명령을 신청하면 안된다. 집행채무자가 이를 문제삼아 부여된 집행문의 효력을 이의신청 등으로 다투기 전이라도 피전부채권의 전부채권자로의 이전이라는 실체법상의 효력은 생기지 않는다.[5] 한정승인한 사실도 채무자가 주장·증명해야 하나, 채권자에 의해 밝혀질 경우(민 1032조 참조)라도 집행문에 상속재산의 한도에서 강제집행을 실시하기 위한다는 내용을 기재하여 집행범위를 명백히 해야 한다.[6]

---

1) 법원실무제요, 민사집행(Ⅰ), 192면.
2) 대법 2003. 2. 14, 2002다64810.
3) 법원실무제요, 민사집행(Ⅰ), 193면.
4) 대법 2021. 9. 15, 2021다224446.
5) 대법 2002. 11. 13, 2002다41602.
6) 상속포기 또는 한정승인을 했다며 이의를 제기하거나 강제집행 정지신청을 하는 경우가 있다. 채권자 역시 잘못된 승계집행문을 발급받은 탓에 집행문 부여에 대한 이의의 소의 피고가 되거나 강제집행에 대한 원상회복의무를 부담하는 등 불필요한 비용을 지출하게 되는 문제점이 있었다. 대법원은 이 같은 문제를 해결하기 위해 승계집행문을 발급할 때 법원 전산시스템을 이용해 채무자의 상속인이 상속포기나 한정승인을 했는지 등을 조회·확인한 뒤 담

제 3 장 강제집행의 진행

제 1 절 강제집행의 개시

집행력 있는 정본을 첨부하여 집행을 신청하여도 집행기관이 강제집행을 개시하기 위하여는 일정한 요건을 갖추어야 한다. 이러한 요건은 집행문부여기관에 의한 집행문부여의 요건으로 하지 않고 집행기관이 스스로 조사 판정하여 집행에 착수하도록 하였는데, 이를 집행의 개시요건이라 한다. 이는 강제집행의 적법요건과 함께 강제집행의 절차적 요건임은 이미 설명한 바 있다. 집행기관이 조사하기 쉬운 것들이다.

Ⅰ. 강제집행의 개시요건

1. 일반집행개시요건-송달

법 제39조 1항 전단은 강제집행을 신청한 사람과 이를 받을 사람의 성명이 집행력 있는 정본(집행권원+집행문)에 표시되어 있어야 집행을 개시할 수 있다고 규정하였다. 보다 중요한 것은 집행권원의 송달이다.

(1) 집행권원의 송달

집행권원이 원칙적으로 집행개시 전 또는 늦어도 집행개시와 동시에 채무자에게 송달되지 아니하면 안 된다는 것이 일반적인 집행개시의 요건이다(39조 1항 후단). 반드시 정본일 필요는 없고 등본이라도 상관없다.[1] 집행증서(공정증서)의 송달에는 공증인법 제56조의5와 민사집행규칙 제22조의2에 특칙이 있는데, 경우에 따라 공정증서정본의 송달을 집행관에게 위임할 수 있다. 민법상의 조합재산에 대한 집행에는 모든 조합원에게 송달하여야 한다.[2] 단순

1) 결정·명령이 집행권원이 될 때에는 정본송달이 필요하다는 것에, 대법 2003. 10. 14, 2003마1144.
2) BGH NJW 2011, 615, 617.

집행문의 경우에는 불필요하지만, **조건성취집행문**(30조 2항), **승계집행문**(31조)이 부여된 경우에는 채무자의 승계인에게 그 집행문을 집행개시 전에 송달하고(39조 2항), 채권자가 집행문을 부여받기 위해 제출한 증명서등본은 집행개시 전 또는 집행개시와 동시에 채무자에게 송달하여야 한다(39조 3항). 채무자에게 어떠한 내용의 강제집행이 행하여질 것인지를 투명하게 알려서 강제집행 내지 집행문부여에 대한 방어의 기회를 주려는 취지이다. 이 원칙의 예외로 집행절차의 간이·신속한 실시를 위하여 송달 전에도 집행절차를 개시할 수 있는 것이 있다. 가압류·가처분명령이 그 예이다(292조, 301조). 2015년부터는 민사집행절차에서도 재래식 송달과 더불어 전자송달(E-mail)이 가능하다.

(2) 송달의 하자

집행권원 등의 송달을 하지 아니한 채 개시된 강제집행은 위법이며, 채무자는 집행이의신청(16조)을 하여 그 취소를 구할 수 있지만, 취소되지 아니하는 한 유효하다고 할 것이다(취소설).[1] 취소되지 아니한 사이에 송달이 되면 그 절차상의 하자(흠)는 치유된다. 판례도 승계집행문을 송달한 증명 없이 강제집행이 이루어져 그에 의하여 경료된 소유권이전등기는 위법이기는 하나 무효라고 할 수 없다고 했다.[2]

그러나 판례는 집행권원이 **허위주소로 송달**된 경우에는 중대한 하자(흠)로 보고, 그 효력은 집행채무자에 미친다고 할 수 없고, 이러한 집행권원에 의하여 집행채무자 소유의 부동산에 대하여 이루어진 강제경매절차는 집행권원 없이 진행된 것이나 다름없다 하여 무효로 보았다(무효설).[3]

2. 특별집행개시요건 — 집행기관의 조사판단사항(40조, 41조)

일반적으로는 집행권원 → 집행문 → 집행권원 송달이 되면 집행기관은 집행을 개시하지만, 집행권원에 따라서는 이와 별도로 집행기관에 의한 조사에

1) 박두환, 189면; 강대성, 132면; 김홍엽, 89면; 전병서, 110면.

2) 대법 1980. 5. 27, 80다438. 독일의 통설.

3) 대법 1973. 6. 12, 71다1252. 동 1987. 5. 12, 86다카2070도 집행권원이 상대방의 허위주소로 송달된 경우에 이에 기하여 이루어진 압류 및 전부명령을 무효라 하였다. 판결정본이 패소자인 피고의 허위주소로 송달된 경우에 엄격히 해석하여 송달무효로 보고 상소기간이 진행되지 아니하는 판결로 취급하여 어느 때나 피고가 항소로 불복할 수 있다는 판례(대법(전) 1978. 5. 9, 75다634 등)와 맥을 같이하는 것으로 보인다.